

1522028-48.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... recomendável.

Nesse sentido: "APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença absolutória - Recurso do Ministério Público postulando a condenação do acusado, nos termos da inicial acusatória, pelo crime de tráfico de drogas, bem como a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, o reconhecimento da agravante da reincidência e a imposição de regime fechado para início do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522028-48.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522028-48.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2247300/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 20178166 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 7095/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2247300 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2247300 - 92º D.P. P. STO ANTONIO, 7095/21/247 - 92º D.P. P. STO ANTONIO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

WESLEY AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

WESLEY AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput e §1º, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de setembro de 2021, por volta de 09h30, na Rua Simão de Miranda, Capão Redondo, nesta capital, trazia consigo, transportava, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 14.300 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como "maconha" e 4.083 gramas de

cocaína, substâncias entorpecentes que provocam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. além de 900ml de acetona, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas.

Notificado, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/06, o acusado apresentou Defesa Prévia (págs. 117/120).

Recebida a denúncia (págs. 141/144), durante a instrução criminal, foram inquiridas as testemunhas arroladas, interrogando-se o acusado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça insistiu na condenação, nos exatos termos da denúncia.

O Dr. Defensor, por sua vez, pugnou pela absolvição e sustentou, em síntese, que a prova produzida é precária. Subsidiariamente, requereu: (I) fixação da pena-base no mínimo legal; (II) aplicação do redutor de pena previsto no artigo 41, da Lei nº 11.343/06; (III) regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado; (IV) detração penal; (V) restituição do veículo apreendido; e, por fim, (VI) seja assegurado ao réu o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

A materialidade do tráfico restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 06 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 07/10); auto de exibição e apreensão (págs. 13/15); laudo de constatação (págs. 29/33); laudo pericial da balança de precisão apreendida (págs. 127/129); laudo de exame químico-toxicológico (págs. 181/184), que apontou para a presença de cocaína e tetrahydrocannabinol nas substâncias analisadas; BOPM (págs. 208/215); laudo pericial do local dos fatos (págs. 308/313); bem como pela contundente prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, nas oportunidades em que foi inquirido, o acusado negou o cometimento do crime, mas apresentou esclarecimentos frágeis e contraditórios.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda no calor dos fatos, perante a D. Autoridade Policial, relatou, em suma, que: "(...) que se encontrava nessa manhã na Rua Simão de Miranda, nessa comarca, acompanhado de um amigo; que em dado momento surgiram policiais militares em perseguição a um desconhecido; que então o amigo com o qual estava conversando, assustado, também correu; que na sequência policiais militares o abordaram, uma vez que permaneceu no local; que empreenderam busca pessoal e também no interior do veículo do declarante, um VW Jetta, sem contudo localizarem nada de ilícito; que ato contínuo o levaram para outra rua bem próxima e um dos policiais militares disse: 'seus amigos fugiram, agora esse BO é seu'; que haviam pessoas no local que presenciaram a abordagem e que os apresentará oportunamente; que então foi conduzido a essa unidade policial prra as providências." (pág. 16).

Em Juízo, já sob o crivo do contraditório, afirmou que havia se dirigido ao local dos fatos para cortar o cabelo; entretanto, o salão estava fechado, de modo que permaneceu no local, aguardando.

Enquanto esperava a abertura do comércio, viu um "menino", que conhecia por "Gordinho", perguntou a ele se tinha conhecimento sobre o barbeiro, ao que ele lhe respondeu que "daqui a pouco ele deve estar abrindo". Em seguida, "Gordinho"

deixou o local caminhando rapidamente.

Na sequência, olhou para o lado e notou a aproximação de uma viatura da força tática. Permaneceu no local, ficou parado e foi abordado pelos policiais militares, que lhe perguntaram se conhecia o rapaz - "Gordinho" - ao que lhes respondeu que sim, mas apenas de vista.

Os milicianos, então, passaram a lhe perguntar se tinha algo de ilícito dentro de seu veículo e se poderiam revistar, de modo autorizou a revista, uma vez que não portava qualquer substância ilícita.

Ato contínuo, os policiais militares revistaram o veículo e, ao final, solicitaram apoio de outra viatura. Quando a outra viatura chegou no local, os milicianos - que sequer conhecia - deliberaram por incriminá-lo pelo fato de já ter registros criminais: "ixi Steve, com passagem, está amarrado".

Assim, eles "apresentaram que tinha um tijolo dentro do carro", ou seja, uma porção de maconha, mas na realidade não havia nada de ilícito no veículo.

De mais a mais, os policiais militares o obrigaram a destravar seu celular, mexeram no referido aparelho, o bloquearam e não falaram nada.

Em seguida, os milicianos que o abordaram dirigiram-se a uma residência nas proximidades, ao passo que os policiais militares que vieram na viatura de apoio o detiveram e o conduziram à delegacia de polícia.

Acrescentou que, pelo que ouviu, os policiais militares teriam se dirigido à residência de João Paulo, seu conhecido, local onde localizaram drogas, o que fizeram por força de uma denúncia anônima que teriam recebido.

Por fim, declarou que, quando chegou na delegacia de polícia, a Autoridade Policial lhe disse que não havia entorpecente apreendido.

Mas referidas exculpatórias, além de pueris, frágeis, contraditórias e inconsistentes, restaram isoladas nos autos, desacompanhadas de qualquer demonstração probatória de veracidade, e foram refutadas cabalmente pela prova adversa - notadamente o firme relato das testemunhas policiais, sem olvidar das incriminadoras circunstâncias da prisão em flagrante que realizaram -, comprometendo sobremaneira o réu.

Os policiais militares responsáveis pela diligência, nas oportunidades em que foram inquiridos, prestaram esclarecimentos coerentes e harmônicos a respeito dos fatos.

Narraram, em suma, que efetuavam patrulhamento pelo local dos fatos - ponto já conhecido pelo comércio espúrio de entorpecentes - e avistaram o acusado e outro indivíduo juntos, caminhando e conversando.

Quando se aproximaram, o indivíduo que conversava com o réu pôs-se em fuga, o que lhes causou suspeitas, de modo que decidiram pela abordagem.

Durante a revista pessoal, nada considerado ilícito foi encontrado em poder do acusado. Entretanto, localizaram a chave de um carro e, diante da postura suspeita dos agentes, pediram para vistoriar o veículo do acusado - o que foi por ele autorizado.

Procederam então a revista do referido automóvel, oportunidade em que localizaram, mais precisamente embaixo do banco dianteiro do passageiro, um tijolo de maconha. Questionado, o réu lhes informou que o entorpecente não lhe pertencia, justificando que teria dado carona para alguns colegas na noite anterior e um

deles devia “ter deixado cair”.

Ato contínuo, o réu abriu o celular e lhes mostrou um vídeo do interior de uma residência, local onde havia entorpecentes, afirmando que : “ó, meu colega mora aqui perto, eu tava na casa dele essa noite, eu não tenho nada a ver com isso aí, eu dei carona pra ele, ele tava no banco de trás, do passageiro, eu nem sabia”, indicando, no mais, o nome do proprietário da residência – João Paulo –, e o endereço do referido imóvel, que ficava a cerca de dois quarteirões do local.

Acrescentaram que, nas filmagens mostradas pelo réu, era possível visualizar o braço do acusado, suas tatuagens e seu relógio, sendo certo que ele estava manuseando uma caixa contendo entorpecentes.

Por consequência, deram voz de prisão em flagrante ao acusado e solicitaram apoio de outra viatura – que permaneceu com ele no local da abordagem. Ato contínuo, dirigiram-se à residência por ele indicada.

Lá chegando, constataram que havia indícios de que alguém havia acabado fugir – já que a luz estava acesa, o ventilador ligado, a porta aberta, e não havia ninguém no local. Por cima do muro, conseguiram visualizar diversos tijolos de substâncias que aparentavam ser maconha.

Assim, ingressaram no imóvel e localizaram entorpecentes diversificados, além de insumos para a fabricação de drogas, uma balança de precisão, um caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas e chaves de automóveis.

Fizeram um patrulhamento nas imediações e, através de tentativa e erro, apertando o botão do alarme da chave, localizaram um veículo compatível. Assim, o vistoriaram e, no compartimento e carga, encontraram mais um tijolo de maconha, enrolado em uma lona.

Diante de tais circunstâncias, conduziram os veículos à delegacia de polícia, mas a Autoridade Policial determinou que os levasse ao local em que ficava a residência, porquanto uma equipe da perícia se dirigiria até lá. No mais, o acusado também foi levado à delegacia de polícia, oportunidade em que a Autoridade Policial ratificou a prisão em flagrante.

Ismael Luiz da Silva, testemunha de defesa, narrou que é vizinho do réu. No dia dos fatos, foi procurado pelo pai dele, que lhe pediu para acompanhá-lo ao local da abordagem.

Desta feita, dirigiram-se ao local, quando chegaram posicionaram-se a cerca de cinco metros de distância, e conseguiram presenciar a inspeção no veículo. Afirmou que os policiais não tiraram nada de seu interior.

Acrescentou que a residência em que os policiais diligenciaram posteriormente fica a cerca de 500 metros do local da abordagem, sendo certo que “ouviu falar por cima” que quem residia nessa casa era “João”, mas não sabe como os policiais militares chegaram nesse endereço.

Por fim, declarou que “em momento algum o réu pegou o celular”.

Diego Henrique da Conceição Machado, também testemunha de Defesa, declarou que não presenciou os fatos aqui tratados. Disse que acompanhou a mãe do acusado até a delegacia. Lá chegando, visualizou o carro do réu e uma Ducato e, na sequência, policiais militares saíram do local com estes veículos.

Por fim, William Carlos Santos, genitor do acusado, ouvido na condição de informante, narrou que algumas pessoas lhe informaram que seu filho havia sido

abordado por policiais militares.

Assim, dirigiu-se ao local da abordagem - localizado a cerca de cinco minutos de distância - e, lá chegando, acompanhou a ação policial.

Relatou que os milicianos olharam as portas, capô e banco de trás do veículo do acusado, mas não os viu encontrando maconha ou retirando qualquer coisa de seu interior.

Por fim, disse que foi até a delegacia de polícia para saber o motivo da prisão de seu filho, oportunidade em que os policiais civis lhe informaram que encontraram drogas em poder dele, mas afirmou que : "não tinha droga nenhuma lá".

Como consignado, a prova produzida no contraditório é farta na demonstração da ocorrência do crime, sendo incontrovertida a autoria.

Nas oportunidades em que foi ouvido, o acusado negou o cometimento do crime, mas apresentou frágeis e contraditórias versões exculpatórias, tentando convencer que teria sido incriminado injustamente pelos policiais militares.

Em solo policial, afirmou que os milicianos surgiram em perseguição a um desconhecido e, na oportunidade, o amigo que o acompanhava se assustou e decidiu se evadir, razão pela qual foi abordado: "o amigo com o qual estava conversando, assustado, também correu; que na sequência policiais militares o abordaram, uma vez que permaneceu no local". Ato contínuo, os policiais militares o conduziram a uma rua nas proximidades e disseram que: "seus amigos fugiram, agora esse BO é seu".

Em Juízo, entretanto, sem qualquer motivo aparente, alterou substancialmente a versão outrora apresentada.

Dessa vez, declarou que estava sozinho no local dos fatos - e não acompanhado de amigos que teriam se evadido ao darem conta da presença da guarnição -, e foi injustamente incriminado pelos milicianos - que sequer conhecia - pelo simples fato de possuir antecedentes criminais.

Mas nem de longe comprovou essas contraditórias versões, como lhe competia fazer, nos termos do que estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Aliás, acatar a falaciosa fala do réu implicaria reconhecer que houve verdadeiro conluio criminoso engendrado pelos policiais militares, com o intuito exclusivo de incriminar pessoa que sabiam ser inocente.

Não parece mesmo crível.

Ao revés, os policiais militares responsáveis pela diligência, nas oportunidades em que foram inquiridos, apresentaram esclarecimentos coerentes e harmônicos a respeito dos fatos aqui tratados.

Esclareceram que o local é notório ponto de venda de drogas, e avistaram o acusado caminhando na via, acompanhado de um indivíduo. Este último notou a presença da guarnição e empreendeu fuga. O réu foi abordado, revistado e portava a chave de um automóvel, que informou que lhe pertencia. Pediram pra vistoriar referido veículo, o foi autorizado pelo réu, e no interior dele lograram localizar um tijolo de maconha, cuja responsabilidade foi negada por ele, uma vez que teria dado carona para alguns amigos na noite anterior, e um deles "devia ter deixado cair". Ato contínuo, o réu lhes mostrou um vídeo em que aparecia manuseando uma vasta quantidade de entorpecentes em uma residência, informando-lhes o endereço, as características e o nome do proprietário do local.

Desta feita, após solicitarem apoio, deram voz de prisão em flagrante ao acusado; dirigiram-se ao local por ele indicado, e localizaram uma vasta quantidade de entorpecentes, de natureza diversificada, além de utensílios comumente utilizados nesse comércio espúrio – balança de precisão, caderno e insumos para a fabricação das drogas, bem como duas chaves de veículos.

Em seguida, apertaram os botões de alarme das chaves e acabaram por localizar um veículo compatível nas proximidades, e no interior dele havia mais um tijolo de maconha.

Desta feita, apresentaram a ocorrência à Autoridade Policial, que ratificou a prisão do acusado.

E os esclarecimentos prestados pelos policiais militares, é sempre bom consignar, são dignos de toda credibilidade, uma vez que não existe demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente, que sequer conheciam.

Como qualquer outra testemunha, os policiais militares prestaram o compromisso de dizer a verdade e a versão que apresentam só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não é o caso dos autos.

Nesse sentido: “Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas”. (TJRJ – AC – Rel Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

Ainda: “Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências.” (RT 417/94).

E ao contrário do que sustentou o ilustre Dr. Defensor, referidos depoimentos não foram contraditórios.

Eventuais divergências em aspectos secundários da dinâmica da diligência – naturais pelo tempo decorrido –, não alteram sua essência, que aponta para a apreensão de todo o material ilícito referido na denúncia sob responsabilidade do acusado.

Por fim, as testemunhas arroladas pela Douta Defesa não presenciaram os fatos aqui tratados, de forma que o conteúdo dos esclarecimentos que prestaram não muda o quadro probatório produzido.

Conforme se verifica do depoimento prestado por William, genitor do acusado, ele somente se dirigiu ao local da abordagem – o que fez acompanhado de Ismael – após tomar conhecimento do ocorrido. Não bastasse, William declarou que reside a cerca de cinco minutos do local em que seu filho foi abordado, tudo a demonstrar que chegaram bem depois da atuação policial, o que justifica o fato de não terem visto a apreensão dos entorpecentes.

Por derradeiro, Diego Henrique da Conceição Machado afirmou expressamente que não presenciou os fatos aqui tratados.

O que se verifica pelos robustos elementos de convicção produzidos é que o acusado era um dos responsáveis pelo armazenamento da vasta quantidade de entorpecentes apreendida – tanto no interior dos veículos, quanto na residência apontada pelos policiais.

Com efeito, conforme informaram os milicianos, "...o próprio acusado indicou o local do imóvel em que as drogas eram armazenadas...", e lhes apresentou um vídeo manuseando entorpecentes naquele local - o que fez na frustrada tentativa de eximir-se da responsabilidade, justificando ainda que um conhecido teria "deixado cair" o tijolo de maconha apreendido no interior do seu veículo.

Não fossem os esclarecimentos prestados pelo acusado, os milicianos jamais teriam localizado referido imóvel, a cerca de 500 (quinhentos) metros do local da abordagem, conforme informado pelo acusado e pela testemunha de defesa Ismael Luiz da Silva.

Enfim, o conjunto probatório é bastante sólido e incrimina sobremaneira o réu, ensejando uma condenação segura.

Quanto ao tóxico apreendido, desnecessário maiores digressões acerca de sua destinação. O desiderato de mercancia é manifesto e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para dúvidas.

A vasta quantidade de entorpecentes apreendida sob a guarda e responsabilidade do acusado - 14.300 gramas de maconha e 4.083 gramas de cocaína -, bem como a balança de precisão, a caderneta contendo anotações do tráfico, e os insumos apreendidos, afastam qualquer dúvida quanto à sua finalidade, de forma que não há que se falar em desclassificação do crime denunciado para o previsto no artigo 28 da Lei Especial, até porque o acusado não reivindicou os entorpecentes apreendidos para consumo pessoal.

Assim não fosse, consigne-se que a situação de usuário de drogas não exclui a de traficante, uma vez que: "Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (TJSP - AC 9.751-3 - Rel. Gonçalves Sobrinho - RJTJSP 75/343).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão dependência, inadmissível - Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76." (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

Por fim, o réu não faz jus à benesse prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/06, uma vez que não admitiu a imputação e não colaborou na identificação dos coautores do crime, limitando-se a indicar aos policiais o local em que era armazenado o restante dos entorpecentes.

E como é cediço, os entorpecentes são objeto - e não produto do crime. O simples fato de ter indicado a localização do restante das drogas, que estavam nas proximidades, não autoriza a aplicação do instituto em apreço.

Nesse sentido: "Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas - (...) Aplicação do art. 41 da Lei de Drogas - Descabimento - Colaboração premiada que não se confunde com a mera confissão judicial - Réu que não forneceu informações que pudessem contribuir decisivamente para a identificação de eventual comparsa ou investigação criminal - Simples apontamento de localização das drogas insuficiente para incidência do instituto - Apelo defensivo parcialmente provido apenas para afastar a nota de Maus Antecedentes, sem reflexo na pena imposta, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos" (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1531099-45.2019.8.26.0228, Relator(a): Juscelino

Batista, 8ª Câmara de Direito Criminal, DJe em: 12/05/2021)

Demonstrada a ocorrência do crime, e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

Os documentos juntados aos autos (certidão e folhas de antecedentes - págs. 108/111 e 101/105, respectivamente), dão conta de duas condenações definitivas suportadas pelo acusado, oriundas da 14ª e 32ª Varas Criminais desta capital, com trânsito em julgado para a Defesa em 18/07/2017 e 11/10/2016, respectivamente, que serão consideradas para fins de reincidência.

Não obstante, as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis. Pela intensidade do dolo que fez parte do comportamento criminoso aqui tratado, demonstrada pela quantidade expressiva de drogas que o acusado armazenava, ou seja, mais de catorze quilos de maconha e mais de quatro quilos de cocaína, o que fazia de maneira bastante estruturada e organizada, uma vez que dispunha também de balanças de precisão, insumos para a fabricação das drogas e cadernetas, tudo a revelar o risco que oferece à saúde pública, já que responsável pelo armazenamento e entrega a terceiros de substâncias altamente nocivas e viciantes, que causam consequências graves aos viciados, às famílias e à sociedade, pelas circunstâncias e consequências do crime, atendendo aos critérios norteadores dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 1/2 acima do mínimo legal, ou seja, em sete anos e seis meses de reclusão e setecentos e cinquenta dias-multa.

Inciduiu a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j' do Código Penal, já que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia da Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020). Não bastasse, o acusado é reincidente - duas condenações geradoras da agravante em questão -, de modo que aumento a reprimenda à razão de 1/4, tornando-a definitiva em nove anos, quatro meses e quinze dias de reclusão e novecentos e trinta e sete dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal.

Cumprе ressaltar que a lei não exige nexo de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime praticado pelo agente. Basta, para o reconhecimento da agravante em questão, que o delito seja executado durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecida por meio dos decretos supramencionados, o que indica insensibilidade moral dos agentes e ausência de fraternidade e solidariedade social.

Nesse sentido: "(...) Agravante do crime perpetrado em estado de calamidade pública - Reconhecimento - Necessidade - Inteligência do artigo 61, II, 'J', do Código Penal. (...) O réu praticou o delito em estado de calamidade pública, no lapso estabelecido no Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março do ano corrente, não se importando com o estado de vulnerabilidade a que submetida a população em geral. É o que basta a subsumir sua conduta ao insculpido no artigo 61, II, 'j', do Código Penal. (TJ-SP - APR: 15101948220208260228 SP 1510194-82.2020.8.26.0228, Relator: Mauricio Valala, Data de Julgamento: 05/11/2020, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/11/2020).

O texto legal estabelece que a pena é agravada se o agente comete o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, nada mencionando sobre a necessidade de nexo de causalidade entre o crime e as situações mencionadas.

Tratando-se de réu reincidente, não estão presentes os requisitos para a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.



E não existe a desproporção no que diz respeito à dosimetria da pena, por conta da reincidência.

Nesse sentido: “A utilização da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I - CP) não impede que seja utilizada na terceira, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º - Lei 11.343/2006). Trata-se de situação processual utilizada com finalidades diversas e com expressas previsões legais. Precedentes.” (STJ - AgRg no HC 662329/SP, Relator(a): Min. Olindo Menezes, T6 - Sexta Turma, DJe em: 11/03/2022).

“Tratando-se de paciente reincidente, ainda que não específico, não há que falar em reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por expressa previsão no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006” (STJ - AgRg no HC 589046/RN, Relator(a): Min. Joel Ilan Paciornik, T5 - Quinta Turma, DJe em: 16/12/2021).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra WESLEY AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS, R.G. nº 48.735.838, e o condeno ao cumprimento de nove anos, quatro meses e quinze dias de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a novecentos e trinta e sete dias-multa, por infração ao 33, caput e §1º, da Lei nº 11.343/06.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente no REGIME FECHADO, quer por força da reincidência, quer pelo que dispõe a Lei nº 11.464/07, que alterou a redação original do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, e, ainda, por força da pena privativa de liberdade fixada.

Tendo em vista a gravidade do crime aqui tratado, considerado hediondo, ainda pela comprovada reincidência e pelas razões consignadas por ocasião da pena-base, o acusado NÃO poderá recorrer em liberdade, deverá ser recomendado na prisão em que se encontra e, igualmente, não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, que não tem aplicação ao crime tratado na presente ação penal, que tem regras especiais e que são aplicadas em detrimento das gerais. Por se tratar de crime hediondo, que compromete a saúde pública, a medida não se mostra socialmente recomendável.

Nesse sentido: “APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença absolutória - Recurso do Ministério Público postulando a condenação do acusado, nos termos da inicial acusatória, pelo crime de tráfico de drogas, bem como a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, o reconhecimento da agravante da reincidência e a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena - Cabimento - Materialidade e autoria comprovadas - 45 (quarenta e cinco) microtubos plásticos encontrados no exato local em que o réu se abaixou, próximo de sua carteira que também foi dispensado pelo Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório - Pena-base fixada acima do mínimo legal, tendo em vista os péssimos antecedentes do réu - Aplicação da agravante da reincidência - Não aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Substituição por restritivas de direitos - Descabimento - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - RECURSO PROVIDO” (TJ-SP; Apelação 0001725-63.2017.8.26.0540; Relator(a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019).

“ENTORPECENTE. Tráfico. Desclassificação em primeiro grau para o delito de posse de tóxico para uso pessoal. Recurso ministerial buscando a condenação pelo crime de tráfico. Circunstâncias da abordagem e quantidade de entorpecente apreendido indicando destinação comercial, segundo os critérios do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06. Condenação por tráfico que se impõe. Dosimetria. Básicas que partem dos mínimos legais, sendo acrescidas de um quinto, na segunda fase, pela dupla

reincidência, a qual, aliás, impede a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/0. Regime fechado necessário, sendo incogitável a substituição das penas corporais por restritivas de direitos. Apelo ministerial provido, com determinação” (TJ-SP; Apelação 0004107-35.2017.8.26.0635; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019).

Pelos fundamentos acima expostos, bem como por tudo quanto produzido no contraditório, presentes os requisitos legais, MANTENHO a prisão preventiva anteriormente decretada, nos termos do que estabelece o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ademais, a medida se mostra necessária, inclusive, para assegurar o cumprimento da pena aplicada.

É certo que o réu está preso desde 11 de setembro passado, mas não é o caso de regime mais brando para início de cumprimento da pena (artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal), porque eventual progressão é matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alíneas “b” e “c” – detração penal, da Lei nº 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei.

Condeno o acusado ao pagamento das custas do processo, nos termos do que estabelece o artigo 804 do Código de Processo Penal. Eventual pleito de isenção de custas deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, momento oportuno para verificação de forma mais detalhada acerca da capacidade financeira do acusado (STJ - 6ª Turma, REsp 1.637.275/RJ).

Nos termos do que estabelecem a Lei 14.322/22 e os artigos 60 e seguintes da lei 11.343/06, determino a perda em favor da União do veículo apreendido às págs. 13/15 (VW/Jetta Variant, placas: GAS-3377, chassis: 3VWTE61K39M266637, álcool/gasolina, na cor prata, ano de fabricação: 2008, modelo: 2009), uma vez que utilizado para o transporte de drogas.

Com relação ao Fiat/Ducato, placas ITQ0062 - também utilizado no transporte de drogas -, verifica-se que foi restituído ao proprietário (B.O. juntado às págs. 240/241). Ao que consta, pertencia a Kleber Júlio Duarte de Oliveira e era utilizado por João Paulo Duarte da Silva Oliveira (pág. 241).

Defiro o requerimento formulado pelo I. Representante do Parquet (pág. 340). Remetam-se cópias dos autos ao Ministério Público para as providências que entender pertinentes no que tange à apuração do envolvimento de João Paulo Duarte da Silva Oliveira no crime aqui tratado.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA